

1503668-23.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... NÃO APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA - PROVA ORAL SEGURA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AFASTAMENTO - INADMISSIBILIDADE - VÍTIMAS MANTIDAS PRESAS NUM CÔMODO DURANTE O ROUBO E APÓS A CONSUMAÇÃO - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - MAJORANTE MANTIDA - RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1503668-23.2021.8.26.0533 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503668-23.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2339053/2021 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 21930207 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 1680/21/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2339053 - 03º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 1680/21/925 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

RAMON DA SILVA, qualificado a fls. 18, THIAGO GOMES DE MORAES, qualificado a fls. 21, e MANOEL GOMES DA SILVA SOBRINHO, qualificado a fls. 22, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 1-3),

[...] no dia 13 de dezembro de 2021, por volta de 22h00min, na Rua dos Tupis, nº 01, Inocoop, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, RAMON DA SILVA,

qualificado a fls. 18, THIAGO GOMES DE MORAES, qualificado a fls. 21, e MANOEL GOMES DA SILVA SOBRINHO, qualificado a fls. 22, agindo previamente ajustados entre si e com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, o veículo VW Jetta, de placas EPK9G12, avaliado em R\$40.555,00 (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de entrega de fls. 16 e auto de avaliação de fls. 19/20), pertencente à vítima Júlio Cesar Santana.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. O recebimento da denúncia foi ratificado e, em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, sendo os réus interrogados ao final. O Ministério Público apresentou suas alegações finais pleiteando a procedência parcial da ação, com a condenação dos réus Thiago e Manoel, e absolvição de Ramon, asseverando que, em que pesem fortíssimos indícios contra ele, não há provas suficientes para a condenação. Na primeira fase da dosimetria, pediu exasperação da pena pelo fato de o crime ter sido cometido na presença de menores e idosos, conforme relato da vítima. Na segunda fase, o reconhecimento da reincidência específica de Thiago e da reincidência genérica de Manoel. Na terceira fase, o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes e de uso de arma de fogo. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu Ramon pela ausência de provas para a condenação. Em relação aos réus Thiago e Manoel, pediu o afastamento da majorante do uso da arma de fogo, reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da pena em seu patamar mínimo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, antes de passar ao mérito da ação penal, imprescindível a análise da nulidade do reconhecimento realizado em sede policial.

O art. 226 do CPP estabelece as regras relativas ao procedimento do reconhecimento pessoal no processo penal.

Assim estabelece o referido dispositivo legal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Assim, a lei prevê que aquele que irá realizar o reconhecimento deve, de início, descrever as características da pessoa que deve ser reconhecida. Em seguida, a pessoa que deve ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela possua em comum alguma semelhança.

No caso em concreto, há indícios de que o referido procedimento foi ignorado, pois o depoimento da vítima em juízo contradiz completamente o que consta no auto de reconhecimento. Vejamos.

No auto de reconhecimento de fl. 20 consta que "o(a) RECONHECEDOR(A) JULIO CESAR SANTANA, o(a) qual descreveu os sinais característicos da pessoas a serem reconhecidas tratando-se (03) indivíduos sendo (02) na cor parda e (01) de cor branca, magros, de estatura mediana, em seguida, em local onde se encontravam várias pessoas, e entre elas os presos" (grifou-se).

Ocorre que a vítima disse em juízo que ao chegar na delegacia não realizou qualquer descrição sobre as pessoas que o teriam roubado e foi diretamente até uma sala, na qual olhou através de uma folha e visualizou apenas três pessoas, no caso, os três réus. A vítima foi enfática ao afirmar que havia ali apenas três pessoas, ao contrário do que diz o auto de reconhecimento.

Não bastasse, a vítima afirmou que no dia reconheceu apenas duas delas, e não as três, conforme também consta no documento de fl. 20.

E, além disso, o policial militar ouvido em juízo, também disse acreditar que apenas três pessoas foram colocadas para que a vítima fizesse o reconhecimento. Não se ignora aqui que, eventualmente, seja viável abrandar o rigor procedimental estabelecido pela lei, porém, desde que seja possível garantir que o escopo principal da garantia legal tenha sido assegurado, o que certamente não se pode dizer que ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, vale observar recente decisão do STJ, que assim entendeu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser

ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

A partir deste entendimento, nota-se que os tribunais superiores passaram a adotar maior cautela com os reconhecimentos feitos por vítimas.

Essa exigência de um maior rigor procedimental é explicada pela alta falibilidade do reconhecimento como meio de prova, conforme explicado no paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), citado no julgado acima colacionado. No referido voto, o Ministro afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”.

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento,

portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). (...)

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que

observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise do problema das falsas memórias e exemplifica à exaustão casos de erros judiciais baseados em reconhecimentos equivocados:

“Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judiciário, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciais, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.p hp. Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1).

Os exemplos erros de reconhecimento no Brasil também não são poucos. Cito alguns, apenas para ilustrar algo que se repete com relativa frequência na crônica judiciária.

Em 2014, o ator Vinícius Romão de Souza foi preso, após haver sido reconhecido por uma mulher que o acusou de tê-lo assaltado. Depois de permanecer 16 dias na prisão, a 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus em favor do acusado, depois que a vítima afirmou, em novo depoimento, que se enganou ao fazer o reconhecimento do ator como o suposto autor do delito.

Reporto, também, o caso de André Luiz Medeiros Biazucci Cardoso, que ficou preso por 6 meses e 26 dias, entre outubro de 2013 e maio de 2014, por sete estupros que não cometeu. Aos 27 anos de idade, foi recolhido no Presídio de Bangu, após uma das vítimas do abuso haver anotado a placa do carro dele e entregue à polícia, afirmando ser o veículo do criminoso. Na delegacia, algumas das vítimas reconheceram André como o estuprador, que chegou a ficar 37 dias na "solitária", sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição, com a consequente liberdade, veio depois de o seu advogado conseguir autorização para feitura de DNA nos resíduos biológicos presentes nas vítimas e nas cenas dos crimes, enquanto ele estava preso. O resultado do teste provou não ser ele o responsável pelos delitos. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no Portal G1: BRITO, Guilherme. 'Aprendi a ter fé', diz inocentado após 7 meses preso por estupros no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/aprendi-ter-fe-diz-inocentado-apos-7-meses-presos-por-estupros-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020).

Registro, ainda, o recente drama vivido pelo violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem de 23 anos, preso por engano no centro de Niterói – RJ em 2/9/2020, por um delito ocorrido em 2017. Segundo a acusação, Justino teria praticado um roubo nesse ano, na companhia de mais três pessoas e com emprego de arma de fogo. A

participação do referido indivíduo foi determinada por reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. Em 5/9/2020, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão do acusado em domiciliar: "Em termos doutrinários, o reconhecimento fotográfico é colocado em causa em função de sua grande possibilidade de erro. A psicologia aplicada tem se empenhado em investigar fatores psicológicos que comprometem a produção da memória. Neste ramo, encontramos contribuições que dissecam as variáveis que podem interferir na precisão da memória", escreveu o Magistrado. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no site do Correio Braziliense: Músico negro que teria sido acusado por engano é libertado no Rio. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873670-musico-negro-que-teria-sido-acusado-por-engano-e-libertado-no-rio.html>. Acesso em: set.2020)

Faço menção, também, ao caso de Douglas Moreira, que foi preso em janeiro de 2014 - ao voltar para casa depois de plantão realizado no hospital Pan-Americano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro -, sob a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, a 39 quilômetros dali. Policiais retiraram uma foto do auxiliar de serviços gerais do seu perfil no Facebook e apresentaram à vítima que, equivocadamente, o reconheceu como sendo o autor do delito (Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/20/vida-travadapreso-com-base-em-foto-inocente-fica-ate-3-anos-na-cadeia.htm>. Acesso em: set. 2020).

Por derradeiro, e sem nenhuma pretensão de esgotar os diversos exemplos de afirmados erros de reconhecimento, registro o recente caso de Lucas Moreira de Souza, que chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão, por suposto envolvimento em uma série de assaltos. A Justiça do Distrito Federal, há poucos dias, reverteu a condenação, em razão das inconsistências na investigação: a única prova apresentada contra o então suspeito era um reconhecimento impreciso feito por testemunhas (Disponível em:

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/21/jovem-de-27-anos-e-absolvido-apos-ficar-quase-3-anos-preso-por-crimes-que-nao-cometeu-no-df.ghtml>. Acesso em: out. 2020)".

Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende aqui desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais.

O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis e justamente por isso precisam seguir os trâmites previstos em lei, para que possam se revestir da credibilidade necessária para servir como prova no processo penal.

Nesse sentido, também há posicionamento do TJSP em recente julgado:

Roubo majorado - Insuficiência probatória - Reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo - Impossibilidade de condenação exclusivamente baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito - Reconhecimentos que não seguiram o procedimento legal - Art. 226 do CPP que não pode mais ser visto como "mera recomendação" - A inobservância do procedimento legal leva à nulidade do ato - Precedentes do STF e do STJ - Busca-se evitar a ocorrência de "falsas memórias" - Inexistência de outras provas que sustentem a condenação - Absolvição dos acusados por insuficiência probatória - Recursos providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1524380-13.2020.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 24/04/2022)

Outrossim, declaro a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, que será desprezado na presente sentença.

Feita esta breve e necessária introdução, passo ao mérito.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

§ 3º Se da violência resulta:

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 12-14), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 18-19), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, restou comprovada quanto aos réus Thiago e Manoel.

Vejamos.

A vítima Júlio César Santana disse que no dia dos fatos estava guiando seu carro quando quatro indivíduos entraram na frente do veículo, um deles armado, e pediu para todos os ocupantes do veículo descerem. Todos desceram do carro e os assaltantes levaram o veículo. Disse que hoje não possui capacidade de reconhecê-los. Após o assalto, os assaltantes foram embora e as vítimas entraram sentido bairro e chamaram a polícia. A polícia chegou em 15 minutos, fizeram perguntas, e pelo rádio avisaram que tinham encontrado o carro, cerca de uma hora após o assalto. Foi até uma praça e seu carro estava lá, havia uma pessoa presa dentro da viatura, mas não foi autorizado que ele visse quem era. Foi até a delegacia, chegou por volta das 23h e saiu quase as 4h. Lá ficou ele e seu cunhado fora da delegacia, sentado, quando começou a chegar diversos parentes dos presos, razão pela qual se sentiu constrangido, acreditando que deveria ter ficado em local reservado, o que não foi feito. Posteriormente, foi até uma sala e olhou por um buraco, haviam apenas 3 pessoas lá, tendo reconhecido 2 delas, os dois morenos. Acredita que um dos morenos era o que estava armado, mas não se recorda exatamente. Quando chegou na delegacia não pediram para descrever as características físicas dos assaltantes, foi direto ver as pessoas na sala, e tem certeza que só havia três pessoas na sala. Feito o reconhecimento dos réus em audiência, a vítima não foi capaz de reconhecê-los.

A testemunha PM Crislaine Aires de Souza disse que no dia dos fatos recebeu informação via COPOM sobre o roubo de um veículo, e que os assaltantes tinham fugido sentido Nova Odessa. Estava em direção a residência da vítima quando recebeu nova informação via COPOM que o veículo estava voltando sentido Santa Bárbara, foi

até o local e visualizou o veículo, tentaram abordá-los, e três saíram do automóvel, deixando o carro em movimento. Um dos assaltantes foi capturado na hora por outro policial. Os três saíram do veículo e o carro continuou em movimento, então a depoente entrou e parou o carro. Não efetuou a prisão pois foi em direção ao carro, mas acredita que o preso tenha sido Manoel. Só teve contato com o preso no plantão. Acredita que Thiago tenha comentado que ele era o piloto, pois mencionou que pegou 160km/h com o carro. Acredita que Thiago seja o da direita, mais claro, que afirmou que estava na condução do veículo. Que Thiago disse que estava na condução e comentou que estariam levando o veículo para Nova Odessa ou Sumaré. Ramon disse que nada tinha a ver com o roubo. Manoel falou que estava "na fita". A vítima teria dito que Ramon era o que estava com a arma. Manoel foi preso em flagrante e os outros fugiram. A viatura encontrou Thiago perto do local, e Manoel confessou que Ramon estaria participando, como ele já é conhecido pela guarda trouxeram ele. Não sabe dizer onde Ramon foi preso.

A testemunha PM Victor Soares Barbosa de Souza disse que estava próximo ao local em que fazia contato com a vítima quando irradiaram que os assaltantes estavam voltando pra Santa Bárbara, e, próximo ao Bairro Santa Rita viu o veículo chegando, e quando os assaltantes viram a viatura desligaram o carro e saíram correndo a pé. Foi possível pegar um deles, mas os outros dois fugiram a pé, sendo que outras duas viaturas foram atrás e pegaram outros dois. O que o depoente prendeu falou o nome dos outros dois. O primeiro detido foi o Manoel, que é o mais magrinho. Ramon é o da esquerda, o do meio é Manoel, que foi o que eu abordei, e o do canto é o Thiago. Manoel falou que os outros envolvidos eram Thiago e Ramon. Presenciou a vítima reconhecendo. Foram colocados só os três no momento do reconhecimento, e acha que a vítima já tinha visto os três antes aguardando. Thiago e Ramon foram presos próximo ao local. O depoente só conseguiu reconhecer mesmo o que prendeu, pois estava escuro, mas os outros pareciam ser os que fugiram do carro, pela estatura, porte físico. Viu os outros na delegacia também. O único que negava era Ramon. Thiago e Manoel assumiram, Thiago até brigava com os outros, com Ramon, pois ele não confessava, ficaram discutindo. Reiterou que não participou da abordagem de Thiago e Ramon pois ficou aguardando com Manoel.

A testemunha Joyce Aparecida dos Santos Souza disse que é sogra do primo de Ramon, contou que no dia dos fatos apurados Ramon ficou em sua casa por volta das 15h, almoçou lá, ficou jogando videogame, depois jogou bola, jantaram lá e foi embora por volta das 22h30, porque Ramon disse que no outro dia trabalhar. Não se recorda se Michely trocou de roupa, ela não saiu de casa, ficou o dia todo lá. Lembra que Ramon estava com um shorts e uma camiseta, mas não lembra de detalhes, não sabe se estava de boné.

O informante Talisson Neres de Lima Santos é primo do réu Ramon. Disse que em 13 de dezembro de 2021 Ramon esteve em sua casa. Contou que estava com sua mulher, filho e sogra e iam fazer um almoço, convidaram Ramon. Foi com sua mulher e filho no mercado, junto com Ramon e a companheira dele, compraram coisas para o almoço, isso por volta das 15h. Depois voltaram para a casa do depoente, onde a sogra fez almoço, comeram, ficaram até tarde jogando videogame no apartamento. Depois o réu foi embora pois iria trabalhar de chapa no outro dia, foi embora por volta das 22h, 22h30. No vídeo da câmera de segurança está ele, a mulher, o primo com a companheira, e o filho. No dia Ramon foi embora com a mulher dele. Ela não trocou de roupa lá, foi embora com a mesma roupa.

A informante Michele Ketely Vieira da Silva disse que é esposa do réu Ramon. Contou que no dia dos fatos foi com seu companheiro almoçar na casa de um primo de Ramon. Foram até o local e depois foram até o mercado, voltaram para a casa do primo, por volta das 15h. Depois do almoço ficaram na casa dele, depois os meninos jogaram bola na quadra, subiram de novo, a sogra do primo fez a janta, jantaram, e por volta das 22h foram embora. Quando estavam passando em um condomínio próximo foram abordados pela polícia e Ramon foi colocado na viatura, tendo a depoente corrido de volta para a casa do primo dele avisar do ocorrido. Disse que Ramon entrou no condomínio com ela, o primo e a mulher, e o filho deles. Na saída, saiu só com a depoente. Tinha trocado de roupa na casa do primo do réu, pois tinha se molhado. Trocou de roupa na casa da mãe, que é do lado. Ramon não trocou de roupa.

O réu Ramon disse que a acusação é falsa. Contou que no dia estava em sua casa quando foi convidado pelo primo para almoçar. Foram as 15h no mercado, compraram as coisas, voltaram pra casa de Talisson. Lá almoçaram, jogaram futebol, jogaram videogame, por volta das 21h subiram pra jantar, esperaram parar de chover e foram embora. Logo no condomínio de baixo foi abordado por policiais, algemado e colocado na viatura por ser suspeito de um assalto. Na delegacia encontrou Manuel, seu ex-vizinho, e Thiago que mora perto da sua casa. Ambos falaram que roubaram um carro e disseram para o réu ficar "suave" que ele não ficaria preso. Manoel disse que falou o nome do réu porque os policiais perguntaram se ele conhecia. Disse que foi embora de Talisson após jantar. Michelle saiu a tarde para ir na casa da mãe dela trocar de roupa porque ela tinha se molhado. Acha que Joice não presenciou esse momento pois estaria na cozinha fazendo comida. O depoente estava de boné azul, camiseta do Tio Patinhos, e shorts jeans. Não viu os vídeos da câmera de segurança.

O réu Thiago confessou os fatos. Disse que estava em um bar e por volta das 21h chegou Manoel, tomaram cerveja e cheiraram cocaína, deram uma volta, encontraram dois amigos de vulgo Baianinho e Pernambuco que estavam com uma réplica de arma e todos decidiram roubar um carro. Entraram na frente do carro, o Baianinho mostrou a réplica, rendeu as vítimas, os passageiros desceram e os assaltantes entraram.

Fugiram sentido Santa Rita e depois foram presos.

O réu Manoel confessou os fatos. Disse que estava no bar com Thiago, foram dar uma volta, encontraram dois amigos e eles chamaram pra participar de um roubo. O homem mais baixo anunciou o roubo e Thiago assumiu o volante, enquanto o depoente foi no banco do passageiro. Quando foi preso os policiais perguntaram se Ramon estava junto e o depoente disse que o conhecia, mas ele não estava lá, mas mesmo assim os policiais pressionaram e por medo acabou dizendo que sim.

Pois bem, percebe-se que a confissão dos réus Thiago e Manoel foi corroborada pelas demais provas colhidas, não havendo dúvida que no dia dos fatos ambos, em companhia com ao menos mais uma pessoa, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo do açougue vítima, perfeitamente delineado o crime de roubo.

Vale dizer que a versão apresentada pelos réus, de que Thiago teria assumido o volante do veículo subtraído está em harmonia com o que foi dito pelos policiais militares em juízo, que disseram ter ouvido o réu se gabando da velocidade que atingiu com o carro.

Também está alinhada a versão dos réus Thiago e Manoel com o que foi dito pelo acusado Ramon, no sentido de que ao chegar a delegacia e encontrar os dois, que já conhecia por terem sido seus vizinhos, perguntou o que havia acontecido e os dois disseram que haviam praticado um roubo de veículo.

Assim, considerando que a confissão dos acusados está em harmonia com todas as demais provas, de rigor a condenação de ambos pelo crime de roubo.

Por sua vez, o mesmo não se pode falar em relação ao réu Ramon. Conforme muito bem apontado pelo representante do Ministério Público, embora haja algumas divergências na versão por ele apresentada, é fato que não se produziu uma única prova em juízo que seja capaz de apontar, com a segurança necessária, que ele contribuiu para o crime em análise.

A vítima não foi capaz de reconhecê-lo, os policiais ouvidos não souberam dizer exatamente como ocorreu sua prisão, os demais réus negaram a participação de Ramon e nenhum objeto ilícito ou proveniente da subtração foi encontrado em seu poder. Assim, não havendo qualquer prova que possa aponta-lo com segurança como um dos autores da subtração, sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP é impositiva.

Passo agora à análise das causas de aumento descritas na denúncia.

A causa de aumento do art. 157, §2º inciso II restou devidamente demonstrada, pois os réus Thiago e Manoel confessaram que agiram com outras duas pessoas para realizar a subtração, fato que está em harmonia com o narrado pela vítima. Embora os policiais tenham dito que visualizaram apenas três pessoas no veículo, é possível que, pela escuridão, não tenham observado o quarto elemento fugindo, ou ainda que ele tenha deixado o carro antes de retornarem sentido Santa Bárbara, o que, de toda forma, é irrelevante, pois a causa de aumento exige tão somente a presença de duas ou mais pessoas, o que é incontroverso.

Também ficou de todo demonstrada a causa de aumento do art. 157, §2º-A do CP, uma vez que a vítima foi incisiva ao dizer que um dos indivíduos que lhe abordou apontou uma arma, afirmando que se tratava provavelmente de um revólver. Nestes casos, a simples menção dos réus de que, em realidade se tratava de simulacro não apreendido, não é capaz de infirmar a palavra da vítima, conforme orienta a jurisprudência dos tribunais:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ARTEFATO NÃO APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA - PROVA ORAL SEGURA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AFASTAMENTO - INADMISSIBILIDADE - VÍTIMAS MANTIDAS PRESAS NUM CÔMODO DURANTE O ROUBO E APÓS A CONSUMAÇÃO - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - MAJORANTE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PENA - REDUÇÃO - PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES - CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO DE ÚNICO AUMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0000021-49.2021.8.26.0548; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Portanto, perfeitamente delineada a tipicidade do crime de roubo duplamente majorado, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que milite em favor dos réus, a condenação de ambos, nos termos acima expostos, é medida que se impõe.

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta a cada um dos condenados.

Primeira fase da dosimetria

Nos termos do artigo 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que praticou o roubo contra quatro pessoas, dentre elas crianças e idosos, fato que deve ser valorado negativamente. Quanto à sua conduta social e a sua personalidade, entendo que não há informações suficientes nos autos para as avaliar. O motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de lucro, o que já é punido pelo tipo penal incriminador. As consequências não se mostraram especialmente graves. Já o comportamento da vítima em nada contribuiu para os fatos.

Por sua vez, as circunstâncias do roubo são graves, afinal o réu abordou a vítimas em concurso com outras três pessoas e utilizando arma de fogo, fatos que certamente causam maior temor às vítimas. Dito isso, é certo que ambas circunstâncias estão previstas como causa de aumento na parte especial, porém, considerando que utilizarei apenas a mais grave (uso de arma de fogo) para majorar a pena na terceira fase (art. 68, parágrafo único, do CP), utilizo a causa sobressalente (concurso de pessoas) na presente fase para reconhecer como grave as circunstâncias dos delitos.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. [...]

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o

parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão. (STJ - HC: 463434 MT 2018/0201182-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Quanto aos antecedentes criminais, o réu possui uma condenação com trânsito em julgado ainda não atingidas pelo período depurador (processo 0003427-26.2021.8.26.0533 - fl. 63). Assim, para evitar o bis in idem, irei desprezar tal circunstância nesta fase e considerar a condenação tão somente para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Portanto, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, no caso, a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo previsto pelo legislador, em 4 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa.

Segunda fase da dosimetria

Presente a agravante genérica da reincidência (artigo 61, inciso I do Código Penal) conforme já explicado.

Presente, ainda a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, vale dizer, a da confissão espontânea, uma vez que o réu, ainda que de forma parcial, confessou ter praticado a conduta que lhe é atribuída, embora tenha negado o emprego de arma de fogo.

Considerando, portanto, a reincidência do réu e sua confissão espontânea, compenso as circunstâncias, mantendo a pena, neste momento, em 4 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa.

Terceira fase da dosimetria

Estão presentes as causas de aumento de pena consistente em concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e uso de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, inc. I). Por conseguinte, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP, aplico a causa que mais aumenta, e acresço 2/3 a pena do roubo, que fica fixada em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência do réu, e da quantidade de pena aplicada nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Levando-se em conta que o período de prisão preventiva cumprido pelo réu até o momento é incapaz de modificar o regime inicial ora fixado, incabível sua alteração em razão do artigo 387, §2º do CP.

Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor